

1501107-21.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... 2019. p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque

Foro de Mairinque

2ª Vara

Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185, Mairinque-SP - cep 18120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501107-21.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501107-21.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153661/2021 - DEL.POL.MAIRINQUE, 18356237 - DEL.POL.MAIRINQUE, 840/21/508 - DEL.POL.MAIRINQUE, 2153661 -

DEL.POL.MAIRINQUE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jorge Walison Vicente

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLA CARLINI CATUZZO

VISTOS.

JORGE WALISON VICENTE, qualificado às fls. 05/06, foi denunciado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 66/68), no dia 07 de junho de 2021, por volta de 16h00, na Rua Professora Dinah Dória Carneiro, Área Central, nesta cidade e comarca de Mairinque/SP, trazia consigo, guardava e transportava, para fins de traficância, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistindo em 3 (três) tijolos de Cannabis sativa L (maconha), pesando aproximadamente 2,936kg (dois quilogramas e novecentos e trinta e seis gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11/12; auto de constatação provisória a fls. 13/14; fotografias de fls. 25/26; e laudo de exame químico-toxicológico requisitado nos autos.

O acusado foi preso em flagrante em 07 de junho de 2021 (fls. 01), a Defensoria Pública do Estado requereu a concessão de liberdade provisória sem fiança (fls. 35/37), tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente ao pedido,

pugnando pela conversão em preventiva (fls. 32/34).

Nos termos da decisão de fls. 40/42, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de plantão judiciário. Mandado de prisão cumprido às fls. 45/46. Impetrado Habeas Corpus em favor do acusado, o pedido liminar foi indeferido (fls. 51/59). As informações foram prestadas (fls. 60/61).

A denúncia foi recebida em 17 de junho de 2021 (fls. 69/70), tendo o acusado constituído defensor (fls. 71/73).

Citação pessoal do réu às fls. 84.

Defesa prévia apresentada às fls. 86/93, vindo acompanhada de documentos (fls. 94/143).

A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva (fls. 144/153), tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente ao pedido (fls. 157/158).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência instrutória, bem como deferida a liberdade provisória ao réu, nos termos da decisão de fls. 159/161.

Alvará de soltura cumprido às fls. 169/172.

Relatório da d. autoridade policial às fls. 174/175.

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela acusação e cinco testemunhas arroladas pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a fase instrutória (fls. 253), o Ministério Público apresentou suas alegações finais na forma de memorial às fls. 260/268, requerendo a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

A defesa do acusado apresentou seus memoriais às fls. 301/348, vindo acompanhado de documentos (fls. 349/368).

Preliminarmente, arguiu: (i) nulidade do auto de prisão em flagrante conduzido por escrivã ad hoc, e , por conseguinte, a nulidade do inquérito policial por ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, em razão da prática de atos privativos de polícia judiciária por agente público incompetente e por ofensa a Lei 12.830/2013, c/c, art. 564, IV, do CPP, devendo, ainda, ser declarada a nulidade de toda ação penal; (ii) quebra na cadeia de custódia, defendendo que não houve a preservação do material apreendido, de modo que a perícia requisitada pela defesa restou prejudicada, requerendo, assim, o desentranhamento do auto de apreensão, declarando a nulidade da ação penal desde o início por inobservância do artigo 158-A c/c artigo 157 do CPP, absolvendo-se o réu, por ausência de materialidade delitiva, nos moldes como preconiza o artigo 386, II, do CPP.

No mérito, apontou a ocorrência de erro de tipo essencial, vez que o acusado tinha falsa percepção da realidade, não sendo de seu conhecimento o que havia no interior da mochila do passageiro, a qual permaneceu a todo tempo no porta-malas. Por tal razão, requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 20, § 1º do CP c/c artigo 397, II do CPP.

Ademais, requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, incisos II, V, VII, do CPP, sob o argumento de que os policiais falsearam a realidade dos acontecidos, com o dolo de prejudicar o réu, considerando que todos os testemunhos foram minimamente arquitetados, com o mesmo propósito. Nessa linha, defendeu a fragilidade probatória e ausência de provas inequívocas aptas para comprovar a responsabilidade pessoal pela posse/propriedade/transporte dos entorpecentes apreendidos, devendo ser observado, ainda, o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59, do CP, não devendo haver, ainda, a incidência do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em seu patamar mínimo.

Na segunda fase, requereu o reconhecimento da aplicação da atenuante inominada do artigo 66, do CP, visto que informalmente forneceu elementos seguros aptos para comprovar que teria recebido a ligação de "Magal", na medida em que poderia a autoridade policial empreender diligências para prendê-lo.

Na terceira fase, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, devendo a pena ser diminuída em patamar máximo, visto trabalhar atualmente com registro em carteira, não se tratar de pessoa criminosa e não possuir qualquer vínculo ou integrar organização criminosa.

Ademais, requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que colaborou em identificar todos os envolvidos no caso dos autos.

Ainda, requereu a fixação do regime inicial em aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E, em caráter subsidiário, em caso de não incidência da benesse do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/03 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação do regime inicial em semiaberto.

No mais, requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade de parte do preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da desproporcionalidade ao cominar como pena mínima ao crime de tráfico a multa no patamar de 500 (quinhentos) dias-multa e, subsidiariamente, o afastamento da pena de multa ou sua fixação em seu patamar mínimo.

Por fim, requereu a detração da pena quanto ao tempo em que o réu ficou preso preventivamente, devendo ser abatido para aferição do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Inicialmente, antes da análise do mérito da pretensão acusatória, impõe-se a análise das preliminares alvitadas pela defesa atinentes à arguição de nulidade do auto de prisão em flagrante, por ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF e por ofensa à Lei nº 12.830/2013 c/c artigo 564, IV, do CPP, anulando-se todos os atos posteriores, inclusive a presente ação penal, bem como a quebra da cadeia de custódia, para que seja declarada a nulidade de toda ação penal.

Por primeiro, acerca da nulidade aventada em razão da condução do auto de prisão em flagrante por agente público incompetente (escrivã ad hoc) impende registrar que a testemunha Gislaíne, arrolada pela defesa, esclareceu, em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório – conforme restará consignado adiante – que apenas redige os termos, não conduzindo os atos de competência da autoridade policial, assim como ocorreu no caso em questão.

Não se olvide, ainda, que os documentos de fls. 01/26, assinados digitalmente pela autoridade policial, vão ao encontro das declarações prestadas pela testemunha em juízo.

Ademais, a jurisprudência é vasta no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória.

Conforme o E. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE AGUARDAR SOLTO A REALIZAÇÃO DO JÚRI PREJUDICADO. EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. 1. (...). 2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. (...) (HC n. 47.960/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 8/11/2007, DJ de 3/12/2007, p. 337. - destaquei)

No mais, a regularidade da prisão em flagrante, bem como a manutenção da custódia cautelar do acusado foi analisada pelo Juízo de Plantão, fundamentada nos termos da decisão de fls. 40/42.

Sendo assim, tal pedido não comporta acolhimento.

No outro ponto, nos termos do artigo 158-A, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime): "considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

Nessa senda, a defesa arguiu a quebra da cadeia de custódia, fundamentando a existência de prejuízo à ampla defesa do acusado, uma vez que não houve a apreensão da mochila na qual as drogas estariam acondicionadas, bem como não houve a preservação necessária para a realização da perícia papiloscópica nos papелotes apreendidos.

Ainda nesse sentido, alegou que a ausência de apreensão do celular do acusado faz presumir a não preservação do material apreendido.

Acerca disso, e a despeito do documentos trazidos pela defesa às fls. 353/356, conforme foi esclarecido com a colheita dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência – consignado adiante – o celular do réu não foi localizado por ocasião de sua abordagem e, por conseguinte, não foi apreendido – vide, ainda, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12.

Ainda, convém aclarar que, em verdade, eventual realização do laudo pericial pretendido pela defesa não sugestionaria a inocência do acusado, na medida em que a denúncia não retrata qualquer contato pessoal direto do réu com as drogas ou a mochila, mas sim o transporte do entorpecente da cidade de Itapevi/SP para Mairinque/SP, sendo incontroverso que o acusado estava na condução do veículo.

Como se vê, não há que se falar em prejuízo ao direito da defesa e, portanto, não se vislumbra a existência de circunstância que balize o pleito da quebra da cadeia de custódia da prova, especialmente porque a narrativa dos policiais civis foi coerente com a prática de condução da droga e do preso à Delegacia, desde a sua apreensão, e, ainda, a cautela demonstrada no laudo pericial de fls. 217/219, não se olvidando, ainda, acerca dos esclarecimentos prestados pela autoridade policial às fls. 248/249.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE COM A PERDA DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020). 2. In casu, não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que, mesmo que comprovado, o fato de não terem sido encartados aos autos alguns depoimentos prestados em sede inquisitorial não desnatura o amplo acervo probatório constituído, nem serve de balizamento para se pleitear a quebra da cadeia de custódia. 3. Ademais, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio *pas de nullité sans grief*, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (Súmula 523/STF). Desse modo, como as provas existentes nos autos ou foram colhidas na fase inquisitorial e posteriormente contraditadas em Juízo, ou foram produzidas em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa em sede judicial, são bastantes para demonstrar que os crimes ocorreram do modo como descritos na inicial acusatória, não tendo a defesa apontado prejuízos ocorridos em razão dos alegados vícios. (...) (AgRg no AREsp n. 1.764.654/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021. - destaquei)

Deste modo, não vislumbrando qualquer atitude que comprometa a cadeia de custódia da prova, especialmente a ausência de repercussão sobre a ação penal, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade apontada pela defesa e no mesmo trilha,

necessária a rejeição da preliminar.

Assim, em que pese a irresignação defensiva, afasto as preliminares aventadas. E, uma vez superadas, passo a análise do mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, em que se imputa ao acusado a prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, que deve ser julgada procedente. Senão vejamos.

A materialidade é incontestada nos autos diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, auto de constatação provisória de fls. 13/14, fotografias de fls. 25/26, laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 129/133, além da prova oral colhida em Juízo.

A autoria também está plenamente configurada com relação ao acusado.

A testemunha arrolada pela acusação, a policial civil Aparecida Daniele Teixeira Costa disse que no dia dos fatos estavam na delegacia, quando receberam uma informação de que uma pessoa da cidade de Itapevi viria para Mairinque em um veículo HB20/Sedan branco, para entregar drogas no centro da cidade. A denúncia foi bem genérica, mencionando apenas tais informações. Disse que o carro com essas características não é comum na cidade. Ficaram nas imediações do centro, quando avistaram o veículo HB20/Sedan branco com duas pessoas a bordo nos bancos da frente, e ingressou em uma viela próxima ao restaurante Tan. A viela não é utilizada costumeiramente pelos habitantes da cidade, pois é uma viela curta, que dá para poucas residências e antigamente dava para os fundos da Delegacia, quando ela estava em reforma. Como a viela tinha um único ponto final, se deslocaram até o local e avistaram que o veículo ingressou na rua sem saída. Como passou um tempo e o veículo não retornou, ingressaram na rua, porque a rua é curta, não tendo muito espaço para dois veículos passarem, pois os moradores locais costumam estacionar seus veículos em cima das calçadas. O veículo estava estacionado. Desembarcaram a pé. Ao lado dele estava o réu JORGE, juntamente com um rapaz. Quando os policiais estavam se aproximando, JORGE fez que ia entrar no carro, mas ficou inerte. Já o outro rapaz saiu correndo, pulou o muro, correu dentro de um terreno e pulou em sentido da linha férrea. A depoente então retornou para o carro. Dentro do veículo continha uma mochila com entorpecentes. Indagado, o réu informou que era motorista de aplicativo e que o rapaz que havia corrido era o proprietário da mochila, que estava dentro do seu carro. O réu foi conduzido para a delegacia, oportunidade em que relatou que conhecia a pessoa de "Magal" do bairro e que por isso aceitou fazer a corrida. Que quando o rapaz o contratou afirmou que viria para Mairinque para comprar uma moto e só depois viu que a mochila continha os entorpecentes e que a mochila não era sua. Questionaram acerca desse rapaz, conhecido como "Magal", mas o réu afirmou não ter conhecimentos mais específicos para identificá-lo. O carro não tinha nenhum adesivo ou sinalizador quanto a ser motorista de aplicativo. O réu informou que o carro era alugado mensalmente e que se valia dos serviços de uber para ajudar na renda. JORGE declarou que a corrida em questão foi particular, não tendo relação com uber. A depoente disse que presenciou a esposa do réu o questionando, quando foi visitá-lo na delegacia, o motivo pelo qual ele continuava fazendo aquele tipo de corrida, que não gostava disso e que eles já tinham conversado a respeito. A esposa confirmou que ele tinha trabalhado durante o dia como uber, assim como o réu havia declarado. A esposa de JORGE verbalizou que iria atrás do que de fato havia acontecido, porque não poderia ter deixado o réu ser preso por drogas que não eram dele. Pela conversa dela, deu a entender que não era a primeira vez que JORGE fazia esse tipo de corrida, fora do aplicativo. A depoente esclareceu que, usualmente, as pessoas que transportam os entorpecentes são de confiança dos traficantes e que eles se valem dessa confiança, pois são pessoas que não levantam suspeita, para fazer esse tipo de viagem. Quando a depoente viu, a mochila estava em cima do banco, já aberta. O policial Samuel relatou que a mochila já estava daquele jeito, aberta, quando fizeram a abordagem do réu. Disse que é comum os traficantes se utilizarem de carro alugado ou de uber para realizar o transporte de entorpecentes. Esses motoristas normalmente tem conhecimento acerca do teor do transporte, sendo de confiança dos traficantes. Não conseguiram abordar o outro rapaz que estava ao lado do réu. Não se recorda de ter um veículo Ford/KA

branco ou outro veículo que tivesse relação com o rapaz que empreendeu fuga. Não se recorda de ter sido apreendido dinheiro com o réu. Não havia aparelho celular com o réu. JORGE mencionou que "Magal" teria feito uma ligação para ele e que ele teria retornado, aceitando a corrida, após ser mencionado o valor. O réu foi questionado acerca da inexistência de seu celular no local, assim como da ausência de "maquininha do uber" ou se o celular dele poderia estar com o rapaz que fugiu.

Pediram para JORGE para ter acesso às informações do solicitante da corrida, para conseguirem localizado, mas o réu disse que não era possível, por conhecê-lo apenas do bairro. A rua não tinha câmera. Os policiais fizeram o percurso na linha férrea, mas localizaram o indivíduo. Disse que o indivíduo era pouco mais alto que a depoente, branco e magro. (sistema audiovisual - fls. 213)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha arrolada pela acusação, o policial civil Samuel Cezar da Silva. Acrescentou que o veículo tinha emplacamento de Minas Gerais. Disse que a mochila estava no banco. Estava aberta e tinha três tablets de maconha enroladas em um plástico. Era bastante maconha. O réu declarou que era motorista de aplicativo, mas que a corrida em questão havia sido contratada de forma particular. Não percebeu se o réu estava com medo de qualificar a pessoa de "Magal". Não foi apreendido nenhum celular com o réu. Não se recorda de haver dinheiro com o réu. Não viu maquininha de cartão no veículo. A denúncia foi anônima, por telefone. A denúncia foi feita no mesmo dia. Saíram para checar. O veículo não tinha nenhum indicativo de que era uber. JORGE foi abordado na parte de fora do veículo. Não visualizaram mais ninguém na rua, que pudessem ter alguma ligação com o réu. A mochila foi localizada no banco traseiro do veículo (sistema audiovisual - fls. 212)

Na mesma linha foi o depoimento da testemunha arrolada pela acusação, o policial civil Agnaldo Pedro de Oliveira, que declarou ter participado da diligência. Foram apreendidos aproximadamente 03kg de maconha. Realizaram diligências na tentativa de localizar o outro indivíduo que fugiu, mas não o localizaram. Não presenciou o indivíduo que empreendeu fuga na posse da mochila antes de serem abordados. Não os presenciou conversando com um terceiro indivíduo. (sistema audiovisual - fls. 211)

A testemunha arrolada pela acusação, o policial civil Adimilson Claro da Rosa Junior declarou ter participado da diligências mais de forma operacional. A abordagem já tinha sido realizada. Tentou localizar o indivíduo que empreendeu fuga, mas sem êxito. (sistema audiovisual - fls. 210)

A testemunha arrolada pela defesa, Gislaine Aparecida de Vaz Chaves, policial civil, disse que teve contato com o réu apenas por ocasião do interrogatório. Disse que o delegado faz as perguntas e ela quem redige. Disse que por ocasião do interrogatório estavam a depoente, o réu e o delegado. Por ocasião do interrogatório, o réu quis prestar suas versões dos fatos, tendo relatado. Depois disso, não teve contato com o réu. Não se recorda se teve contato com algum familiar do réu, acredita que só para entregar roupa. Declarou ter digitado o registro de ocorrência no dia dos fatos. Declarou ser escrivã ad hoc, cedida pela prefeitura para a polícia civil há 27 anos. (sistema audiovisual - fls. 206)

A testemunha arrolada pela defesa, Silvana Oliveira da Silva declarou conhecer o réu em razão de ter trabalhado com a mãe dele. Não tem nada a dizer que o desabone. Disse que nessa época JORGE trabalhava como uber. Já contratou corridas de forma particular com o réu de dezembro a abril. (sistema audiovisual - fls. 209)

A testemunha arrolada pela defesa, Graciane Carvalho de Souza declarou conhecer o réu há 29 anos, do bairro que moram. Na época dos fatos, o réu trabalhava como uber. Nunca chegou ao seu conhecimento de que fosse envolvido com drogas. Disse que o réu é solteiro e ao que se lembra ele não tinha namorada na época. Atualmente o réu ainda trabalha como uber. Contrata corridas particulares com o réu. (sistema audiovisual - fls. 208)

A testemunha arrolada pela defesa, Luciano Afonso Viana declarou conhecer o réu há cinco anos. Sua esposa trabalha com a genitora de JORGE. Atestou seus bons antecedentes. Afirmou contratar os serviços do réu como uber. (sistema audiovisual - fls. 207)

A testemunha arrolada pela defesa, Jéssica Cristina Silva Soares declarou conhecer o réu em razão da corrida por aplicativo (uber). Declarou sempre se utilizar dos

serviços dele, há dois anos. (sistema audiovisual - fls. 204)

A oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Andrea Cristiane de Souza restou prejudicada em razão da desistência manifestada pela parte, homologada judicialmente às fls. 202/203.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu Jorge Walison Vicente declarou ter 29 (vinte e nove) anos e não ter filhos. Trabalha como motorista de aplicativo. Acerca dos fatos, disse que trabalhou desde às 09 horas da manhã e recebeu a ligação em torno de 12:30 horas a 13:00 horas. Ele lhe passou o nome da rua e fez a simulação por meio do aplicativo para saber qual seria o valor da corrida. Na simulação deu o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais), o que foi aceito pelo solicitante. Disse que ao chegar no local não desceu do carro. Abriu o porta-malas para o indivíduo e não tinha acesso ao que ele estava levando. A corrida foi particular. Ele entrou em contato por telefone. Já tinha feito corrida para ele por meio do próprio aplicativo. Disse que ele conseguiu o número do depoente em razão de já ter esquecido algo no carro em corrida anterior. Disse que estava com celular por ocasião de sua prisão. Disse que seu celular sumiu e não foi apresentado. Disse que estava dentro do carro e não saiu em nenhum momento. Disse que quando chegaram ao local havia um Ford/Ka branco esperando pelo indivíduo. Disse que o indivíduo não levou seu celular embora. O celular estava no painel do carro até a delegacia.

Atualmente possui a mesma linha, mas com outro aparelho. Disse que quando o indivíduo foi embarcar para dar início à corrida era uma rua sem saída e ele não tinha nada nas mãos, depois ele pediu para o depoente abrir o porta-malas do carro. Abriu e ele colocou a mochila no porta-malas. O indivíduo ficou sentado no banco da frente e ele ficou falando no celular. O indivíduo falou que estava esperando um Ford/Ka branco, o qual chegou e parou mais à frente. O indivíduo pediu, então, para que o réu abrisse o porta-malas, pegou a mochila e foi em direção ao outro carro. O interrogado declarou não ter descido em nenhum momento do seu carro. O indivíduo desceu do seu carro, retirou a mochila e foi em sentido do carro branco. Quando os policiais chegaram, o indivíduo correu. O terceiro do carro branco, não sabe dizer. A mochila estava no Ford/Ka branco. O indivíduo que estava no Ford/Ka branco não fugiu. Só pegaram a mochila da mão dele e ele foi embora. O rapaz do Ford/Ka branco aparentemente estava com eles. O indivíduo que contratou a corrida pediu para que o interrogado esperasse, quando chegaram no local. Não conhecia os policiais anteriormente aos fatos. Disse que a testemunha Gislaine é quem fez o interrogatório; o delegado não estava no local. Já era cerca de 19:00 horas. Disse que não questionou nada, pois nunca tinha passado por isso. Disse que era comum receber ligações para fazer corrida. Disse que em nenhum momento chegou a encostar na mochila. Disse que no dia dos fatos fez nove corridas e acabou não recebendo nada pela corrida em questão. (sistema audiovisual - fls. 205)

Conforme restou apurado, os policiais civis ouvidos em juízo, atuantes nesta urbe, por ocasião dos fatos já haviam sido cientificados previamente por meio de denúncia anônima via telefone de que haveria uma descarga de drogas no município, procedentes de Itapevi/SP, e que os fatos envolviam um veículo Hyundai/HB20 de cor branca.

Dotados de tal informação, iniciaram as diligências, logrando êxito em localizar o veículo em que estava a bordo o acusado e o comparsa sentado no banco do passageiro, com as mesmas características descritas na denúncia, e que, conforme enfatizado pelos policiais (sistema audiovisual), não se tratava de veículo costumeiramente encontrado em circulação nas vias públicas da cidade.

Sendo assim, empreenderam as diligências necessárias à efetivação da realização da abordagem, visualizando os dois indivíduos ao lado do automóvel, oportunidade em que desembarcaram da viatura descaracterizada e foram ao encontro dos indivíduos, desempenhando a abordagem.

O passageiro empreendeu fuga e no interior do veículo alugado pelo acusado encontraram uma mochila sobre o branco traseiro, já aberta, saltando aos olhos os tablets de maconha que nela continham.

Pois bem.

O crime de tráfico é classificado como tipo misto alternativo, pois basta a prática de um dos diversos núcleos previstos na capitulação do delito para que este seja

considerado consumado, e no caso dos autos, o réu “trazia consigo”, “guardava” e “transportava”, caracterizando a tipicidade exigida pelos princípios do direito penal.

A autoria do réu é verificável pela teoria do domínio funcional do fato, em que cada um dos indivíduos exerce um papel de engrenagem na empreitada criminosa como um todo, com funções relevantes para a consecução do delito final, normalmente divisível entre diversas pessoas (“olheiro”, “mula”, “vapor”, “aviãozinho”, etc.). Assim é que somente com a atuação fracionada de cada um dos agentes, o crime pode se consumir em sua forma acabada, exatamente como se verifica no caso em apreço. Nos dizeres de Luiz Régis Prado: “todo aquele que participa da finalidade típica dolosa, e toma parte na divisão do trabalho é coautor” (Tratado de Direito Penal Brasileiro. vol. 1. Forense. 2019. p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra transporta (ainda que contratada eventualmente para tal fim), outra fiscaliza, outra cobra, outra anota e infinitas outras funções que existem a depender do tamanho da organização.

No caso dos autos, os elementos de convicção colhidos no transcorrer da instrução processual permitem a segura conclusão de que o acusado tinha conhecimento que transportava as drogas apreendidas no interior do seu veículo, especialmente diante do seguro e coeso testemunho prestado pelos policiais civis ouvidos em juízo, os quais foram uníssonos ao afirmar que, por ocasião da abordagem, a mochila na qual as drogas estavam acomodadas encontrava-se aberta sobre o banco de trás do carro, sem qualquer dificuldade para visualizar os tabletes de maconha em seu interior, além de não ser localizado aparelhos de corrida ou máquinas de pagamento ou outros indicativos de que naquele momento atuava como motorista convencional, seja de aplicativo ou particular, ainda que haja registros de corrida realizados naquele mesmo dia (fls. 104/109).

Reforço: o fato de atuar como motorista particular ou de aplicativo não exclui a possibilidade de ter sido contratado para o transporte de entorpecentes e ser conhecedor de tal condição, ainda mais diante do quadro probatório delineado nos autos.

A versão apresentada pelo acusado restou isolada nos autos, ausente de lastro probatório a evidenciar a retidão de sua narrativa por ocasião dos fatos.

Nessa linha, não passou despercebido, ainda, as contradições apresentadas pelo acusado em sede policial e as prestadas sob o crivo do contraditório.

Isso porque, na fase extrajudicial o acusado declarou que não conhecia a pessoa de “Magal” e que nada sabia sobre ele, considerando-o como um cliente de aplicativo que lhe solicitou para fazer uma corrida particular (fls. 05/06 e 174). Já em juízo, declarou que já tinha feito corrida para ele por meio do próprio aplicativo (sistema audiovisual).

Ademais, afirmou que em nenhum momento saiu do seu veículo e que o passageiro da corrida já havia entregado a mochila para um terceiro, de quem os policiais haviam retirado das mãos, e que supostamente estaria com eles, não sendo levado para delegacia.

Por outro lado, repita-se, os policiais civis que atuaram na ocorrência apresentaram versões unânimes no sentido de que a mala estava no interior do veículo do acusado, aberta, mostrando seu conteúdo (entorpecentes), além de que o réu estava do lado de fora do veículo quando realizaram a abordagem, discordando acerca da existência de um terceiro indivíduo – abordo de um veículo Ford/Ka branco – que estivesse recebendo drogas do passageiro-contratante.

No mais, por ocasião de seu interrogatório policial, o acusado em nenhum momento mencionou que começou a estranhar o comportamento do passageiro no transcorrer do caminho, antes de chegarem ao local combinado em Mairinque, diante de inúmeras ligações e conversas suspeitas, o que o fez em juízo, ao que parece, apenas para delinear o cenário de sua alegada inocência, diante da ventilada tese de erro de tipo essencial.

Nessa senda, cumpre considerar, ainda, que tanto o réu quanto os policiais declararam não se conhecerem anteriormente aos fatos, sinalizando a inexistência de motivos para os policiais falsamente incriminarem o acusado.

Ao contrário, elucidaram convincentemente como se deu o início da diligência (denúncia); a abordagem; e o encontro dos entorpecentes (no interior do veículo, em mala aberta, estando visível seu conteúdo), não havendo razão para desprestigiar tais agentes públicos, que compareceram perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.

Acerca da valoração dos testemunhos policiais, aliás, não é de hoje a farta jurisprudência: "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 74.608-0 Rel. Min. Celso de Mello j. 18/02/97).

Ainda:

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram, a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840) De mais a mais, as testemunhas de defesa Silvana Oliveira da Silva, Luciano Afonso Viana, Jéssica Cristina Silva Soares e Graciane Carvalho de Souza em nada contribuíram ao acervo probatório, limitando-se a atestar os bons antecedentes do réu, bem como a atuação do acusado como motorista de aplicativo e particular. Em arremate e prestigiando as provas requisitadas pela combatente defesa no sentido de que o acusado em verdade tem como ocupação lícita a de motorista, a análise do conjunto probatório não permite afastar a narrativa trazida pelos policiais civis em juízo, sob o viés de que o transporte de drogas foi realizado pelo réu com pleno conhecimento de que se tratava de conduta ilícita, não se podendo subestimar, ainda, a preexistência de denúncia anônima que indicava a ocorrência do transporte de drogas a bordo do automóvel HB20, de cor branca, o que ensejou nas diligências policiais e posterior abordagem.

Vale anotar, ademais, que a substância entorpecente transportada, pela grande quantidade e forma de acondicionamento - 03 (três) tijolos de Cannabis sativa L (maconha), pesando aproximadamente 2,936kg (dois quilogramas e novecentos e trinta e seis gramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11/12 e fotografias de fls. 25/26 - denotam, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros.

Bem é de ver, portanto, a despeito do esforço defensivo, a versão exculpatória, inverossímil, não merece credibilidade, estando bem provadas a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se deduz do acervo probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório.

A condenação, portanto, é de rigor.

No mais, quanto ao pedido de reconhecimento da aplicação da atenuante inominada disposta no artigo 66, do Código Penal, não há qualquer registro nos autos ou narrativa em juízo - até mesmo por parte do próprio réu, em sede de interrogatório - que tenha fornecido informalmente elementos aptos ao deslinde da ação penal.

Ao revés, verificou-se que na fase extrajudicial o acusado declarou não conhecer a pessoa de "Magal" e que nada sabia sobre ele, considerando-o como um cliente de aplicativo que lhe solicitou para fazer uma corrida particular (fls. 05/06).

Do mesmo modo, não se vislumbrou a existência de qualquer circunstância relevante que justifique sua aplicabilidade, de modo que deixo de acolher o pedido.

Por fim, a despeito do pedido da defesa quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade de parte do preceito secundário do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, acerca da cominação da pena de multa, oportuno consignar inexistir

qualquer inconstitucionalidade.

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça Paulista, quando do julgamento da Apelação nº 990.10.003484-7, de relatoria do eminente Desembargador Francisco Bruno (voto nº 4368):

“Não há a alegada inconstitucionalidade da pena de multa cominada pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, considerando que, ao contrário do alegado pela defesa, o preceito secundário da norma em questão não fere qualquer princípio constitucional, especialmente aqueles ventilados no recurso, quais sejam, da isonomia e da individualização da pena. A quantidade da pena de multa cominada ao crime guarda relação com sua gravidade, assim a pena mínima de multa prevista para o crime de tráfico de entorpecente é elevada em virtude da extrema gravidade do delito, não havendo, portanto, inconstitucionalidade. Os princípios da isonomia e da individualização da pena não sofreram qualquer mácula em razão da quantidade de pena cominada, em abstrato, ao crime, isto porque, no momento do cálculo da pena, deve o julgador observar as especialidades do caso concreto, bem assim a personalidade do agente, procedendo da forma determinada pelo art. 68, do Código Penal, como forma de garantir que a pena aplicada seja adequada às hipóteses verificadas, em estrita observância aos princípios constitucionais invocados”

(TJSP; Apelação Criminal 0003484-77.2010.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2010; Data de Registro: 19/07/2010). Restando apenas a dosagem da pena, o que ora faço observando o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código de Processo Penal e artigo 42, da Lei nº 11.343/03.

Na primeira etapa, em observância ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal, verifico se tratar de réu primário (fls. 372/375) e as circunstâncias do delito são normais à espécie. Sendo assim, inicio o cômputo da reprimenda em seu patamar mínimo, correspondente a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, diante da ausência de comprovação acerca da atenuante inominada alegada pela defesa, com fulcro no artigo 66, do Código Penal, entendo não haver circunstâncias atenuantes a serem consideradas ao caso em tela. De igual modo, inexistem agravantes a serem consideradas.

Na última etapa, pondero se tratar de réu primário, que não parece integrar organização criminosa, pelo que faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dos terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, tornando-a definitiva em razão de outras circunstâncias modificadoras.

A despeito dos documentos trazidos pela defesa às fls. 108/129 e 359/368 e ante a ausência de outras informações quanto à capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos.

Excepcionalmente, preenchendo o acusado os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade imposta em 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta (01 ano e 08 meses), e pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a ½ (meio) salário mínimo a instituição público ou privada de destinação social a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Neste sentido:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Apelo do Ministério Público desprovido – Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal – Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa – Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – Viável a

substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa – Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP – Precedentes do C. STJ e do E. STF – APELO DO MP DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos – Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020 - destaquei)

Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuarão a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020 - destaquei)

Posto isso, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para o fim de CONDENAR JORGE WALISON VICENTE, qualificado às fls. 05/06, como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no patamar mínimo (1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Sem prejuízo da multa imposta, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam: (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida em sede de execução de pena, pelo prazo da pena imposta (ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses) e (ii) prestação pecuniária no valor equivalente a ½ (meio) salário-mínimo à instituição público ou privada de destinação social a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Diante da pena imposta e das circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, o sentenciado poderá recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Após o trânsito em julgado: Inscreva-se o nome do réu no sistema informatizado do tjsp; Oficie-se ao IIRGD, bem como ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado, comunicando a suspensão de seus direitos políticos, com a máxima urgência, nos termos do comunicado cg nº 296/2022, a fim de que seja consignado no caderno de votação da respectiva seção eleitoral o impedimento ao exercício do voto do eleitor definitivamente condenado; Se o caso, e se ainda pendente, determino a destruição das drogas, certificando nos autos, nos termos do artigo 72, da lei nº 11.343/06 (redação dada pela lei nº 12.961, de 2014); providenciando-se, ainda, o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta.

Custas na forma da lei.

Oportunamente arquivem-se os autos, com as cautelas de ofício.

P.I.C. Sentença Registrada Eletronicamente, nos termos do art. 72, §4º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Mairinque, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA